

1506739-54.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... relativos à apuração de atos infracionais equivalentes ao tráfico de drogas, a jurisprudência é clara:

"A propósito, a prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas pode ser considerada como dado a obstar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 (STJ, HC nº 420.720, rel. Min. Félix Fischer; HC nº 423.378 e HC nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506739-54.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506739-54.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2156363/2021 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 18406596 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1557/21/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NÍCOLLAS LORENZO SOUZA LOURENÇO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

NÍCOLLAS LORENZO SOUZA LOURENÇO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 09 de junho de 2021, por volta de 19h09min, nas imediações da área de lazer, conhecida como "Campo do Cridão" e na Rua João Fernandes Vieira, nº 65, situadas no Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Salto-SP, trazia consigo e guardava 1.010 (mil e dez) porções de "cocaína", 02 (duas) porção de "cocaína" em sua forma petrificada popularmente conhecida como "crack" e c) 01 (uma) porção de "Cannabis Sativa L" (maconha), contendo a substância tetrahydrocannabinol (THC), sem autorização.

O réu foi devidamente notificado e apresentou defesa prévia dentro do prazo legal (fls. 103/118). A denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2021 (fls. 165/168).

Sobreveio decisão, em sede de recurso de Habeas Corpus, de nº 2179576-

84.2021.8.26.0000, proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar (fls. 151/155).

Houve parcial provimento aos embargos de declaração apresentados pela Defesa, sanando-se o erro material da decisão de fls. 165/168, no tocante ao pedido atinente à cadeia de custódia da prova (fls. 184/185).

Sobrevieram decisões, em sede de recursos de Habeas Corpus, de nºs 2193100-51.2021.8.26.0000 e 689635 - SP (2021/0273681-7), proferidas, respectivamente, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo, em ambas, indeferidos os pedidos liminares (fls. 197/200 e 210/214).

Em sede de exceção de suspeição nº 0034013-93.2021.8.26.0000, sobreveio decisão monocrática proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rejeitando a exceção de suspeição e determinando seu arquivamento (fls. 510/519). Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas em comum, 04 testemunhas arroladas pela defesa (fls. 570) e, em seguida, o réu foi interrogado (fls. 571).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade e fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena, bem como entendeu não ser possível a concessão benesse do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, entendendo ser também inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Ao final, requereu a extração de cópias e disponibilização das mídias para instauração de inquérito policial, por falso testemunho (fls. 620/637). A Defesa, por sua vez, suscitou preliminares e, no mérito, pugnou pela improcedência da ação por insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da agravante atinente ao estado de calamidade pública, reconhecimento da menoridade relativa do acusado e observação da menor culpabilidade do réu, em virtude de situação de vulnerabilidade social. Pugnou, ainda em sede subsidiária, pela aplicação de menor percentual para exasperação no tocante ao artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 e concessão benesse do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com fixação de regime diferente do fechado, para início de cumprimento de pena privativa de liberdade, com a substituição desta última por restritivas de direitos (fls. 644/682).

É o relatório.

Decido.

As preliminares apresentadas pela Defesa não merecem acolhimento, pois não restou demonstrada qualquer mácula à cadeia de custódia, pois os entorpecentes foram apreendidos no local dos fatos e devidamente apresentados à Autoridade Policial, que elaborou o competente Auto de Constatação Preliminar dos entorpecentes (fls. 11), remetendo-os ao Instituto de Criminalística de São Paulo (fls. 17), em consonância com os parágrafos 1º e 2º do art. 50 da Lei nº 11.343/2006. Também não há que se falar em afronta ao artigo 158-A do Código de Processo Penal e a suposta quebra da cadeia de custódia das provas, porquanto não se comprovou nenhum vício que pudesse ter causado prejuízo efetivo à defesa, devendo-se aplicar ao caso o disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Neste sentido, reproduzo os julgados já colacionados a fls. 184/185, por serem extremamente pertinentes aos pedidos:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelo em que se pretende a absolvição por falta de prova da materialidade do crime, pois teria havido quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas. Inocorrência. Drogas encontradas em revista pessoal, apresentadas à autoridade policial em auto devidamente elaborado, com lacração e remessa a perícia oficial. Inexistência de irregularidade. No mérito, pretendida desclassificação para a forma privilegiada. Apelante reincidente específico. Óbice legal expresso. Possibilidade de afastamento da agravante referente à situação de calamidade pública. Ausência de demonstração de efetiva majoração do risco da conduta ou aproveitamento da situação pelo agente. Precedentes. Regime inicial fechado necessário. Apelo provido em parte." (TJ-SP APR: 15033196220218260228 SP 1503319-62.2021.8.26.0228, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento:

17/08/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de publicação: 17/08/2021).

Ainda:

"PROCESSO-CRIME - NULIDADE - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - INOCORRÊNCIA - TRÁFICO ADEQUADA APREENSÃO, PRESERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA DROGA À AUTORIDADE POLICIAL, COM ENCAMINHAMENTO FINAL À PERÍCIA - DESNECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SACOLA EM QUE ESTAVAM ACONDICIONADAS AS PORÇÕES DO ENTORPECENTE - PRELIMINAR REJEITADA." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 1506007- 10.2020.8.26.0526, da Comarca de Salto, 3ª Câmara, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. em 1º de junho de 2021).

Conforme se verá a seguir, o conjunto probatório é suficiente para a análise do crime narrado no presente feito. Ademais, o pueril argumento de que dentro da mochila haveria cerca de R\$10.000,00 em drogas e que o réu não teria poder aquisitivo para ter consigo tamanho patrimônio simplesmente não vinga. Ora, é mais que sabido que as enormes quantidades de droga que transitam pelas cidades e são frequentemente apreendidas pela polícia, estão circulando para abastecer pontos de vendas e não são pagas por seus transportadores, a serviço do tráfico. Os envolvidos simplesmente transportam, entregam, separam em porções, repartem e distribuem os lotes, e executam as mais diversas funções ligadas ao comércio do entorpecente, mas nenhum deles foi pago antecipadamente, como se houvesse uma transação bancária ou comercial regular, quitações em espécie, com emissão de pedidos e notas fiscais !!! Portanto, sobre não ter havido a nulidade alegada acima, tampouco subsistiria, pelo fundamento acima, completamente falho, razão para que se fizesse a perícia reclamada na mochila, porque eventual droga apreendida, não havia sido comprada antecipadamente e paga em dinheiro, em transação regular e documentada, pelo réu.

Assim, rejeito as preliminares arguidas.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito ficou incontroversa, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 14), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de constatação preliminar (fls. 11) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 95/98), além da prova oral, colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime ficou exaustivamente confirmada.

O réu, em sede policial, negou o tráfico de entorpecentes, dizendo que não trazia consigo as drogas apreendidas (fls. 05/06). Em juízo, disse que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Informou que tinha trabalhado das 8:00h até as 17:00h e que conversou com o Breno e foram à praça e sentaram no banco. Contou que neste momento, passou um menino correndo e a viatura passou em perseguição a ele, e que então decidiu ir embora, pois iria à casa da Gabriela. Contou que quando chegou, chamou a "Gabi", mas chegou a viatura e ele foi preso e algemado. Disse que na Delegacia de Salto não viu droga nenhuma e, apenas na Delegacia de Itu, conversou com o advogado, e ele disse que uma grande quantidade de droga teria sido apreendida, e soube que eram 1.000 pinos e mais nada. Contou que, no dia seguinte, quando foi para a audiência de custódia, soube que teriam apreendido mais microtubos além dos 1.000 já mencionados, e do dinheiro. Contou que sua mãe abriu um bar/lanchonete no bairro Laguna, mas ele "tinha parado com as drogas", porque sua mulher ficou grávida. Disse que já teve um passado com passagens na Infância, e informou que estudou até o 1º ano do ensino médio, mas estava fazendo supletivo na escola Dolores. Por fim, alegou ser perseguido pelos guardas municipais (fls. 571). Marcos Roberto Carlos, guarda municipal, disse que estavam patrulhando o bairro, mais precisamente o Campo do Cridão e, ao entrarem no local, avistaram o réu, já bastante conhecido pela prática de tráfico, trazendo consigo, no guidão da bicicleta, uma bolsa escolar cinza e, ao ver os guardas, o réu empreendeu fuga pela pista de bicicross e dispensou a mochila escolar, continuou fugindo e adentrou a rua Manoel Preto, onde parou a bicicleta, jogou-a e correu no contra fluxo da viatura. Contou que os guardas correram e que o acompanhou de viatura, tendo visto quando o réu jogou mais tarde, alguns volumes. Disse que o réu tentou entrar numa casa da rua, mas os moradores negaram sua entrada, e ele foi abordado. Informou que os volumes dispensados por ele eram 9 (nove) porções de cocaína em microtubos azuis, 2 (duas) porções de crack e uma porção de maconha e R\$120,00 (cento e vinte

reais). Contou que na mochila, havia 1000 (hum mil) microtubos azul de cocaína e mais 180 (cento e oitenta) gramas de cocaína, a granel. Disse que voltou no local onde estaria a bike, mas ela não estava mais lá, e contou que o réu disse que havia se assustado com a presença da viatura e por isso, fugiu, e que ele negou qualquer propriedade da droga apreendida. Informou que o réu era muito conhecido por denúncias de moradores e usuários que o apontavam, como gerente de parte do tráfico de drogas no bairro. Disse que os guardas Malinski e Eduardo participaram da ocorrência (fls. 570).

Anselmo Malinski, guarda municipal, prestou depoimento em perfeita consonância com o de seu colega, acrescentando que a amásia do réu apareceu e foi avisada da prisão dele, e ainda disse que não conversou com os moradores da casa em que o réu tentou entrar (fls. 570).

Reginaldo Willian Francisco, testemunha de defesa, disse que estava na praça e viu o réu passando de bicicleta, e que havia bastante gente na praça. Contou que ele parou, brincou com seu neto. Disse que não viu o réu portando bolsa e nem mochila. Contou que ele passou no meio da praça, e pegou a Cásper Líbero. Disse que já ouviu um GCM falando que iria pegar o réu e não iria dar sossego para ele, contou que não viu o momento em que ele foi abordado. Informou que viu as viaturas correndo pela praça, mas que não sabia que era atrás do réu (fls. 570).

Gisleine Donizetti do Espírito Santo, testemunha de defesa, disse que estava subindo para congregar e viu quando o réu passou correndo e vinha uma viatura atrás dele. Informou que não o viu dispensar nada, e que não viu a abordagem do réu. Disse que soube, após sair da igreja, que o réu havia sido preso. Informou que a mãe do réu é professora da sua filha (fls. 570).

Breno dos Santos Pinheiro, testemunha de defesa, disse que estava com o réu, que disse que iria descer para a casa da Gabi. Contou que estavam sentados do outro lado das árvores e viram um moleque que saiu correndo pelo meio das árvores. Disse que o réu não tinha nada consigo. Informou que a viatura entrou na praça e saiu correndo atrás do moleque e que não sabe mais o que aconteceu. Disse que não viu nenhuma perseguição com relação ao Nicollas (fls. 570).

Gabriela da Silva, testemunha de defesa, disse que no dia, o réu iria passar o dia na sua casa, ele chamou na entrada, cerca de duas vezes e logo em seguida, os guardas chegaram. Contou que os guardas pediram que ele se retirasse e mandaram-na entrar. Disse que entrou e não conseguiu acompanhar mais nada. Contou que na data dos fatos, sua mãe e seu tio estavam em sua casa, mas não acompanharam nada e não deu tempo deles saírem. Disse que o Nicollas entrou no imóvel e então pediram para ele sair. Afirmou que o Nicollas não possuía nada, disse que foi na delegacia e conversou somente com o Delegado. Disse que na data da abordagem, só viu uma viatura.(fls. 570).

Em que pese a negativa do réu e a versão apresentada pelas testemunhas apresentadas pela Defesa, é certo que elas se mostraram isoladas do restante do conjunto probatório. Outrossim, esperar que se dê total crédito às testemunhas de defesa, convocadas para sustentar teses absolutórias fantasiosas e cujos depoimentos estão em franca contradição entre si e com o próprio bom senso, seria cancelar por completo a total inversão de valores e determinar que réu algum seria condenado pelos crimes que comete, contanto que arrolasse testemunhas em seu favor.

Neste palmejar, exigir, para comprovação de autoria em delitos de tráfico, filmagens das câmeras de segurança também equivaleria a relegar à impunidade, grande parte dos crimes. Inicialmente, há que se pontuar que as referidas câmeras nem sempre estão bem reguladas, funcionam a contento ou têm imagens nítidas. Não bastasse, é notório que as gravações são apagadas regularmente, pois nenhum desses comércios, instalados em bairros modestos, dispõe de sistema de preservação, estocagem ou gravação ininterrupta das imagens. E, por fim, ainda que assim não o fosse, o que se admite apenas para argumentar, caso a gravação tivesse ocorrido de forma perfeita e provasse a ocorrência do delito, é evidente que o proprietário da câmera ficaria temeroso de entregar tal prova, por receio das notórias represálias que recaem sobre os que delatam o tráfico, já que os demais envolvidos no crime e que não foram detidos, não hesitam em se vingar e impor um clima de silêncio forçado. Tais circunstâncias traduzem os obstáculos encontrados na busca de imagens gravadas

referentes ao comércio ilícito de entorpecentes e explicam porque são tão raras de se ver, nos tão numerosos processos instaurados por tal delito.

Os guardas municipais que efetuaram a prisão do réu prestaram depoimentos seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

No mesmo sentido:

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Ainda:

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido, o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Portanto, seus depoimentos devem ser plenamente considerados, até porque, contrariando as alegações do réu, inexistente qualquer indício nos autos de que pretendiam, deliberadamente, prejudicar o acusado. A versão do réu, imputando conduta criminosa aos guardas municipais, não deixou o terreno especulativo, até

porque, enquanto não se demonstrar, efetivamente, qualquer desvio de conduta dos agentes públicos, devidamente apurada na esfera policial e administrativa, a versão destes últimos não pode ser descartada, mormente porque se coaduna com o restante do conjunto probatório.

Assim, em que pesem as alegações da Defesa, nenhuma prova foi trazida aos autos, capaz de demonstrar vícios na conduta dos guardas municipais, de modo que as alegações não deixaram o terreno das especulações.

Cumprе salientar que os depoimentos das testemunhas de Defesa foram vagos e nada acrescentaram ao panorama probante, já que nenhuma delas acompanhou, efetivamente, a perseguição e a prisão do réu.

O fato da testemunha Gisleine não ter visto Nicollas dispensar nada não significa que ele não o tenha feito, antes ou depois de passar "correndo" por ela, que não acompanhou a abordagem.

O mesmo se aplica à testemunha Reginaldo, que disse não ter visto o réu portando bolsa ou mochila. Ademais, não esclareceu em que contexto teria ouvido a suposta declaração de "um GCM falando que iria pegar o réu e não iria dar sossego para ele", mormente porque ainda declarou que, no dia dos fatos, viu as viaturas correndo pela praça, mas que não sabia nem mesmo que estavam atrás do réu.

Já Breno disse que não acompanhou e nem presenciou qualquer perseguição a Nicollas, o que causa estranheza, pois contradiz por completo a fala da testemunha Reginaldo e das demais, que narraram ter havido a movimentação de viatura no local, em diligências.

Por fim, Gabriela, disse que ninguém de sua casa acompanhou a abordagem, mas afirmou saber que Nicollas não tinha "nada"(!), fato este que se mostra óbvio pelo conjunto probatório, já que a mochila foi dispensada no percurso, durante a perseguição. Todavia, se nada presenciou, não tem como atestar que o acusado simplesmente não fez nada, no interregno que antecedeu a suposta chegada à sua casa.

Não há como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial."

(TJBA Bahia Forense 18/173)

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546)

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).

Encerrada a instrução, ficou evidenciado à saciedade que o réu praticou a infração que lhe foi atribuída na denúncia, sendo incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 09 de junho de 2021, por volta de 19h09min, nas imediações da área de lazer conhecida como "Campo do Cridão" e na Rua João Fernandes Vieira, nº 65, situadas no Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Salto-SP, trazia consigo e guardava 1.010 (mil e dez) porções de "cocaína", 02 (duas) porção de "cocaína" em sua forma petrificada popularmente conhecida como "crack" e c) 01 (uma) porção de "Cannabis Sativa L" (maconha), contendo a substância tetrahidrocannabinol (THC), sem autorização.

O pedido da Defesa de não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal não merece acolhida. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do

Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 09 de junho de 2022, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Por fim, comprovada a incidência da causa de aumento prevista no artigo, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, porque o local da ocorrência do crime de tráfico, conforme se verifica pelo croqui de fls. 584, consistia em recinto público onde se realizam atividades e diversões de natureza esportiva e de lazer, local este conhecido como "Campo do Cridão".

Em suma, ficou provada de forma incontestada a ocorrência do delito mencionado na inicial e a conduta do acusado, razão pela qual, passo a lhe aplicar as sanções cabíveis, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atenta às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e também às do artigo 59 do Código Penal, mormente à grande quantidade de entorpecente apreendido e, ainda, porque parte da droga consistia em porções de crack, cujo devastador potencial lesivo é incontestado, e, ainda, em razão da diversidade (cocaína, crack e maconha), fixo a pena-base do acusado acima do mínimo legal, qual seja, 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa para o delito de tráfico (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Como acima mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Entretanto, incide a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, já que o réu era menor de 21 anos de idade à época dos fatos.

Assim, agravante e atenuante devem ser compensadas, permanecendo a pena, neste momento, como inicialmente fixada.

Por fim, aplica-se a causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da lei em comento, razão pela qual aumento a pena do acusado de 1/6, resultando na pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, além de 641 dias-multa.

Ainda que as passagens do réu pela Vara da Infância e Juventude, por prática de atos infracionais, não possa e não deva ser utilizada como antecedentes criminais, certamente se prestam a demonstrar sua personalidade.

Convém colacionar trecho de precedente da Quinta Turma do STJ:

"conquanto o ato infracional equiparado a homicídio qualificado praticado pela Paciente não possa ser considerado para fins de reincidência, ou mesmo como maus antecedentes, serve perfeitamente para demonstrar sua periculosidade, bem assim sua propensão ao cometimento de delitos da mesma natureza" (HC n.º 33.614/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 2-6-2005, DJ 20-6-2005.)

No mesmo sentido, o seguinte julgado:

"HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. (...) 2. Embora o envolvimento anterior em atos infracionais não possa ser considerado como maus antecedentes, pode ser valorado como personalidade desfavorável, o que é suficiente para justificar o aumento de pena procedido na primeira etapa da dosimetria. Precedentes. 3. Ordem denegada" (HC 169.755/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 21/08/2012).

Sobre a utilização de processos relativos à apuração de atos infracionais equivalentes ao tráfico de drogas, a jurisprudência é clara:

"A propósito, a prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas pode ser considerada como dado a obstar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 (STJ, HC nº 420.720, rel. Min. Félix Fischer; HC nº 423.378 e HC nº 299.673, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC nº 333.749, rel. Min. Joel Ilan Pacionik; HC nº 121.509, rel. Min. Jorge Mussi; AgRg no REsp nº 1560667, rel. Min. Nefi Cordeiro). Ainda nesse sentido: '...o entendimento seguido pela Corte estadual encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça, no sentido de que a existência de anotações penais, ainda que não transitadas em julgado e o registro de atos infracionais, podem justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando permitam concluir a dedicação do réu à prática delituosa' (STJ - AgRg no REsp n. 1.846.479/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/5/2020)" (TJSP, 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal nº 1500705-97.2020.8.26.0526, Des. Rel. Paiva Coutinho, DJe 19/08/2021).

Assim, considerando que o réu possui inúmeras representações, em razão do tráfico, em que lhe foram aplicadas medidas socioeducativas e, ainda assim, continuou a se enveredar pelo caminho da ilicitude após completar dezoito anos, mostra-se impossível a aplicação do previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, já que se mostra latente sua dedicação às atividades criminosas.

"Além disso, esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido, por ambas as Turmas, que a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 505.248/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e CONDENO o réu NÍCOLLAS LORENZO SOUZA LOURENÇO, qualificado nos autos, RG 50.580.489, como incurso no artigo 33, caput c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, e artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 641 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, não apenas em razão da gravidade do delito praticado (Súmulas 718 e 719 - STF; Súmula 440 - STJ), mas sobretudo pela grande quantidade e enorme potencial lesivo da droga encontrada em poder do acusado, além da abrangência de sua conduta, e também por entender que, neste caso específico, somente o regime fechado será suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, vez que demonstrada a dedicação criminosa do réu e, com sua conduta de distribuir a droga para venda, iria atingir milhares de usuários, propagando ainda mais o uso desenfreado. Acrescente-se a isso que o réu possui passagens, em sua adolescência, por tráfico de drogas, sendo-lhe aplicadas medidas socioeducativas, o que não inibiu a reiteração da conduta, com o único diferencial de que possui, agora, mais de dezoito anos, o que reforça a necessidade de sua segregação. Determino, ainda, que o réu não poderá recorrer desta sentença em liberdade, considerando que sua custódia foi determinada durante todo o decorrer do feito, permanecendo presentes os seus requisitos. Pelas mesmas razões, não se mostra viável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Neste sentido, a jurisprudência oriunda de caso análogo desta Vara submetido a recurso:

"[...] , a evidenciar que faz do crime meio de vida e que a condenação anterior não foi suficiente para reeducá-lo, tanto que persiste na empreita delitiva, a justificar o tratamento mais severo. Ademais, não se pode desprezar que a traficância é a mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade, circunstância que, por si só, justifica a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena. Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça: 'TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, uma vez que o magistrado possui a discricionariedade de agravar somente o aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido. (HC 300.274/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015).' (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0000274-81.2015.8.26.0569/50000, Rel. Desembargador WILLIAN CAMPOS. 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em

11/04/2019).

Considerando a redação do art. 387, parágrafo 2º, do CPP, forçoso reconhecer que não se aplica ao presente caso, uma vez que não demonstrados os requisitos subjetivos para a progressão pleiteada, os quais deverão ser aferidos pelo juízo da execução. Neste sentido:

"Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654- 12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015).

Recomende-se o réu onde se encontra preso.

Ao contrário do que alegou a combativa Defesa, restou demonstrada a origem criminosa dos valores apreendidos. Portanto, decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06) e, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Defiro o pedido de extração de cópias formulado pelo Ministério Público a fls. 637, ressaltando que a impugnação apresentada pela Defesa não tem elementos suficientes a impedirem o deferimento, sendo certo que as alegações apresentadas a fls. 682 podem, certamente, ser apresentadas em eventual inquérito policial ou processo criminal que se originem das cópias extraídas.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA